

以憲法解釋方法試評日本同婚判決—以福岡高裁及東京高裁判決為中心¹

李婉瑜²

¹ 東吳大學 114 學年度第 2 學期，課程名稱：憲法專題研究（四），授課教師：湯德宗教授，報告日期：2026 年 6 月 15 日。

² 東吳大學法律學系公法碩一，學號：14341323。

目錄

壹、前言.....	1
貳、日本違憲審查制度介紹及日本同婚訴訟發展.....	1
一、日本違憲審查制度.....	1
二、目前日本同婚訴訟發展.....	2
參、日本同婚訴訟之涉案條文及爭點.....	2
一、憲法第 24 條：婚姻自由.....	3
二、憲法第 13 條：幸福追求權.....	3
三、憲法第 14 條：法律上平等權.....	4
四、小結.....	4
肆、福岡高裁與東京高裁之憲法解釋方法.....	5
一、福岡高裁.....	5
二、東京高裁.....	6
三、小結.....	7
伍、解釋方法分析.....	8
一、福岡高裁解釋方法分析.....	8
二、東京高裁解釋方法分析.....	9
三、小結.....	10
陸、結論.....	11
參考文獻.....	12

壹、前言

從 2017 年釋字第 748 號解釋做成，到《司法院釋字第 748 號解釋施行法》自民國 108 年 5 月 24 日施行至今，相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。對我而言似已習以為常，直至本期學習憲法解釋方法，看到美國同婚案件及我國釋字第 748 號解釋，始注意到鄰近的日本近年也在爭執同婚，又將時空拉回從前看孽子的氛圍，目前已孑然不同，尚非完美但社會風氣確實改變許多。

由於日本違憲審查制度採分散審查制，各級法院皆有審查權，從 2019 年日本版婚姻平權訴訟「讓所有人都能結婚」運動開始以來，目前 6 個法院 12 案件均已上訴到最高裁，最快 2027 年作出裁決。日本同婚主要爭執的法條為憲法第 24 條、第 13 條及第 14 條，卻在總共 12 個判決中得出各種不同的結論，其中差異即在解釋方法。究竟應該司法積極或消極？對社會重大爭議，司法權應採取怎樣的角色？本文選擇兩個日本高裁判決，試用本學期所學分析該判決之解釋方法。

本文擬先就日本違憲審查制度介紹開始，再介紹目前日本同婚訴訟發展，其次介紹日本同婚案件之主要爭點，接續以憲法解釋方法試分析兩個日本高裁判決，分別是東京高裁及福岡高裁，分析各以何種釋方法以導致結論不同，最後提出本文見解及結論。

貳、日本違憲審查制度介紹及日本同婚訴訟發展

一、日本違憲審查制度

日本之違憲審查制度是二次世界大戰後始建立，二戰投降後，以美國為代表的盟軍佔領日本，麥克阿瑟將軍指令當時近衛內閣修改憲法，於 1946 年制定出了以松本烝治為首的「松本草案」，與明治憲法無實質區別。不利於維護美國對日本的統治，故麥克阿瑟遂提出修改憲法的三原則，主要是反制：保留天皇制、日本放棄作為國家主權權利之戰爭、廢除封建制度。1946 年 10 月 29 日天皇批准麥克阿瑟版本的憲法修正案，違憲審查制度明定於日本國憲法第 81 條中，確立其違憲審查制度為美國式之附帶型審查制³。

依日本國憲法第 81 條規定：「最高法院是有權決定法律、命令、規則或處分是否合憲的終審法院。」，日本在二戰後，在當時歷史背景及國際政治情勢下，採行美國式的附隨類型之違憲審查，換言之，即由各級普通法院執掌司法審查許

³ 張震，我國與日本違憲審查制度之比較，社科法政論叢，4 期，頁 97-98（2016 年）。

可權，即分散制，僅能於審理具體民刑事訴訟事件中附帶審查，並由最高法院即最高裁為違憲審查之終審法院⁴。另，較為特殊的是，日本違憲審查權採極端消極主義，理由為：外塑的憲法民主化不足及長期一黨執政、法官任命制度和任期短暫、官僚型法官與追求明哲保身之裁判、日本傳統文化注重「和」的共同體主義及權利配置不合理與司法權之地位⁵。

二、目前日本同婚訴訟發展

綜上所述，日本違憲審查制度採分散制，各級法院皆得針對個案進行違憲審查，2019 年 2 月 14 日西洋情人節這天，日本同運團體找來 13 組同性伴侶，分別在東京、大阪、北海道和名古屋提告，正式啟動日本版婚姻平權訴訟「讓所有人都能結婚」(Marriage For All Japan，以下簡稱「日版婚姻平權訴訟」)。

日版婚姻平權訴訟分別在：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡提訴，再加上東京有「東京 1 次訴訟」和「東京 2 次訴訟」的差別，東京第 2 次訴訟，原告團的組成更加多元，特別加入了跨性別者與泛性戀者，等於有 6 案同時並進。另一方面，各地方的各級法院審理過程彼此獨立，一審（地方法院）與二審（高等法院）判決結果也可能有所不同，目前為止已有 12 場判決結果。目前皆已上訴至最高裁⁶。

參、日本同婚訴訟之涉案條文及爭點

日本民法未明文禁止同性婚，但憲法第 24 條第 1 項使用「夫妻」一詞，民法第 739 條第 1 項規定婚姻生效須依戶籍法登記，而戶籍法第 74 條規定由「夫妻」辦理結婚登記，導致同性婚在法律上不可能。從 1945 年二戰戰敗後的戰後改革中，建立了以夫妻為中心之現代家族形象，係以生育為目的之結合。近年「家族性結合」開始多樣化，性取向和生育逐漸分離，家族關係中的人格與愛情關係受重視，同時，性別平等的問題亦受嚴厲質疑⁷。

⁴ 張震（註 3），頁 100-102。

⁵ 張震（註 3），頁 105-109。

⁶ 張郁婕，日本同婚訴訟的一大挫敗：系列訴訟二審首度出現合憲判決，2026 年決戰最高法院，2025 年 12 月 1 日，https://global.udn.com/global_vision/story/8664/9174443（最後瀏覽日：2026 年 6 月 9 日）。

⁷ 山元一，日本的同性婚與憲法（張惠東譯，日文原名：「日本における同性婚と憲法」），公法研究，9 期，頁 49-52（2024 年）。

憲法學中的家族問題，有「家族關係中個人自由保護之要求」及「家族集團之社會性保護之要求」相互交錯，近年家族問題成為日本憲法訴訟中重要課題，下面就同性婚姻的憲法理論定位分述之：

一、憲法第 24 條：婚姻自由

日本憲法第 24 條第 1 項「婚姻僅基於兩性之合意而成立，夫婦具有同等之權利作為根本，並應以相互之協力予以維持。」⁸同條第 2 項「配偶之選擇、財產權、繼承、住居之選定、離婚以及婚姻和家庭等其他有關事項，法律，必須基於個人尊嚴與兩性本質之平等制定之。」⁹，於家庭關係中導入個人主義理論，係為確立夫婦間之平等與自由結婚之權利。就第 24 條第 1 項，「同性婚姻禁止說」仍為通說。憲法自始僅將男女結合視為婚姻，進入此種男女結合關係之自由即為「婚姻自由」，其他的共同生活或人的結合之自由並不包含在其中。

而相反見解認為，第 24 條第 1 項，意在保障家庭形成自由及在婚姻中之男女平等並非積極禁止同婚。「兩性」則指「各自獨立的兩方的性別」解釋上可包含女女、男男。第 24 條第 2 項，家族制度須「個人尊嚴」合致來立法，禁止同婚，即違反此意旨¹⁰。

二、憲法第 13 條：幸福追求權

日本憲法第 13 條「每個公民都應受到尊重。在立法和國家治理的其他方面，人民的生命權、自由權和追求幸福的權利應得到最大程度的尊重，只要不與公共福利相衝突。」¹¹。肯定同婚之學說認為，憲法雖未明文規定婚姻自由，但憲法第 13 條保障之「幸福追求權」包含婚姻自由。

反對說認為，不能僅憑本條要求國家必須向各種類型之家庭皆提供平等保護。「婚姻自由」係以制度為前提的權利，作為制度中之自由，一方面，對立法權所為的制度內容形成中立法裁量劃下界線；同時也，對於每個人都要保障因此形成

⁸ 日本憲法第 24 條第 1 項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」。

⁹ 日本憲法第 24 條第 2 項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」。

¹⁰ 山元一（註 7），頁 52-54。

¹¹ 日本憲法第 13 條「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」。

的制度內容。若採德國制度性保障之觀點，不可不經過修憲僅以修法方式，改變歷史上、傳統上所形成之婚姻制度之核心部分¹²。

另外，對前述觀點反向思考，則憲法第 24 條第 2 項「法律必須基於個人尊嚴...為基礎」、保護同性婚也有助於保護同性伴侶的子女，透過創建某種形式的同性伴侶制度來賦予同性伴侶保護，應視為第 24 條第 2 項積極要求的。

三、憲法第 14 條：法律上平等權¹³

憲法第 14 條第 1 項「法律面前人人平等，不得因種族、信仰、性別、社會地位或家庭出身而在政治、經濟或社會關係中受到歧視。」，婚姻制度可取得一定特權，即享受民法及其他各種法律上之便益。從憲法第 14 條及第 24 條出發，若不承認同性婚姻與異性伴侶相較，同性伴侶則處於被法律差別待遇之狀態，係對平等權之侵害。

平等權不僅涉及財產權及利益分配，還應理解為具有禁止國家賦予特定群體「劣性的污名」之意旨，不允許同性伴侶與異性伴侶是用相同制度本身，以向社會傳達對同性伴侶之負面訊息。基於此看法，若以「準婚姻」、「視為婚姻」等名稱之情形，或明顯的被認為劣於異性婚姻的話，可能以污名化為由，主張係對平等權之侵害¹⁴。

四、小結

綜上所述，目前日本同性婚系列訴訟基本上係以上述問題為主要爭點，從憲法第 24 條明文規定「夫婦」、「兩性」，到第 13 條之幸福追求權及第 14 條之法律上平等權，從 2021 年開始，日本法院陸續作出判決。相同法條分別得出不同結果，關鍵點即在解釋方法，本文以下選出合憲、違憲判決各一，試分析其解釋方法，論述何以得出不同結果。

另外，日本現行法制不允許同婚，若屬國家怠於立法，即立法不作為，致原告之權益或精神受損即可情求國賠，但最終判決是否認定國家須賠償，非本文之重點，是以本文僅就法院對上述憲法條文之解釋方法分析。

¹² 山元一（註 7），頁 55。

¹³ 日本憲法第 14 條第 1 項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的關係において、差別されない。」。

¹⁴ 山元一（註 7），頁 57-59。

肆、福岡高裁與東京高裁之憲法解釋方法

依照日本學者河北洋介之分類，地院判決群共同處是承認現行婚姻制度不包含同性婚姻，將問題界定為缺乏同性婚姻或類似制度，換言之，即接受婚姻以外的替代制度；高院判決群則轉向聚焦於婚姻制度本身¹⁵，類似於我國釋字第 748 號解釋之論理，嘗試抽離「性別」因素，重新確認婚姻本質¹⁶，且兩個判決分別得出相異結果，是以本文選擇此兩裁判加以分析。

一、福岡高裁

（一）憲法第 13 條：違憲

直接從憲法第 13 條導出以婚姻獲得法律保護的具體權利。法院指出，當事人不受他人干涉而締結婚姻的自由，不僅受到憲法第 24 條第 1 項的保障，也同樣受第 13 條保障。憲法第 13 條不僅止於保障關於是否結婚之個人自由，亦承認關於婚姻的成立及維持受法制度保護的權利，而此種權利可說是該條所定之幸福追求權的內涵之一¹⁷。考量到婚姻對人而言是極為重要且根本的權利，作為幸福追求權一環的「就婚姻獲得法律保護的權利」，是個人人格生存不可或缺的權利，也是可以在法庭上尋求救濟的具體權利。

性傾向具不可變性。現行法完全剝奪同性伴侶受婚姻保護及繼承等重要法律效果，阻斷其幸福追求，構成重大侵害；且戶籍等行政技術問題絕不能作為推託的藉口。現行法並非單純考量婚姻制度的「內容」設計，而是對同性伴侶「根本未設立」婚姻制度。此種對特定群體權利的徹底剝奪，已明確超越國會立法裁量權的容許界線。承認同婚對異性戀權利「毫無損害」，不生人權衝突，故不違公共福祉。法院直指，基於生殖或宗教的歷史偏見皆已失效，多數群體純粹的「不安感」，絕不能合理化對少數群體的權利剝奪。基於上述理由，將同性伴侶排除在婚姻制度之外，直接違反了憲法第 13 條對於「個人尊重」的保障¹⁸。

¹⁵ 河北洋介，同性婚訴訟に関する一考察，慶應法學，NO.56，頁 190-192（2026 年）。

¹⁶ 湯德宗，釋憲學思心路，頁 1394（2025 年）。

¹⁷ 福岡高等裁判所令和 6 年（2024 年）12 月 13 日判決（令和 5 年（ネ）第 584 号）。判決第 11 頁「…そうすると、憲法 13 条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一つであるといえる。…」。

¹⁸ 判決第 12-14 頁。

（二）憲法第 14 條第 1 項：違憲

現行法僅給予男女伴侶婚姻的法律地位與保護，卻將同性伴侶完全排除在外。這種徹底剝奪同性伴侶利用法定婚姻制度的差別待遇，欠缺任何合理根據，違反了憲法第 14 條第 1 項法律的平等原則。同項後段規定之「性別」而未列舉「性傾向」，同項後段僅為對同項前段平等原則的例示性說明。法官認為，法條明文禁止的項目僅是舉例，所有「不合理的歧視」皆受平等原則禁止。既然前面已認定禁止同婚侵害了第 13 條（幸福追求權），這種侵害基本權利的差別待遇「理所當然」屬不合理，必定違反第 14 條。

雖然許多地方自治體導入了伴侶制度，使同性伴侶在一定程度上獲得了認可；如前所述，作為幸福追求權之「關於婚姻的成立及維持受法制度保護的權利」，應解為男女伴侶與同性伴侶皆同等享有。因此，因不認可同性伴侶利用法定婚姻制度所造成的不平等，並不能透過擴充伴侶制度，或導入如歐洲諸國可見之登記伴侶制度來加以消除。對於同性伴侶，若不直接允許其利用與異性婚相同的法定婚姻制度，則違反憲法第 14 條第 1 項的狀態便無法消除¹⁹。

（三）憲法第 24 條：違憲

憲法第 24 條雖使用「兩性」、「夫婦」等文字，但其真正的歷史目的是為了掃除明治民法下不平等的「家父長制」（如戶長同意權與妻子的從屬地位），並非為了刻意禁止同性婚姻。關於婚姻與家族生活不能將第 24 條孤立看待，其規範內容必須與憲法第 13 條（個人尊嚴／幸福追求權）及第 14 條（平等權）的價值軌跡保持一致。

受限於「兩性」的字面文義，難以直接宣告禁止同婚違反第 24 條第 1 項。但既然前面已認定排除同性伴侶違反了第 13 條的個人尊嚴，那麼這種剝奪權利的現行法律，理所當然違反了「要求婚姻立法必須立基於個人尊嚴」的憲法第 24 條第 2 項²⁰。

二、東京高裁

（一）憲法第 24 條：合憲

法院指出，憲法第 24 條第 1 項規定「婚姻應僅基於兩性之合意成立」，其制憲背景是為了排除明治民法下「家長父權制度」對婚姻的限制，貫徹個人尊嚴與兩性平等的原則。在制憲當時，「婚姻」預設為歷史與傳統上「異性之間」的結

¹⁹ 判決第 15-16 頁。

²⁰ 判決第 16 頁。

合關係，審議過程中完全沒有涉及同性結合的討論²¹。

法院認為，雖然今日社會對於同性之間的事實婚已有廣泛的承認，但這種「社會狀況的變化」應該是國會在建構具體家族制度時納入考量的「社會因素」，而不能透過司法解釋，直接將憲法第 24 條第 1 項的「婚姻」概念擴張包含同性結合。法院也同時排除了對同性事實婚「類推適用」該條款的可能性²²。

憲法第 24 條第 2 項要求家族與婚姻立法必須「以個人尊嚴及兩性本質的平等為基礎」。要宣告違憲，必須是立法機關的怠惰達到了「合理性明顯欠缺、超越國會立法裁量範圍」的程度。基於前述的社會替代保護措施及國會動態，法院認為「現階段」尚未超越此一裁量界線。

（二）憲法第 14 條：合憲

現行法律婚制度是建構在以「一對夫妻及其子女」作為社會基礎構成單位的制度設計上。法院特別引用數據指出，目前日本嫡出子（婚生子女）的比例仍維持接近 100%（2021 年為 97.5%），這顯示該制度設計目前依然具有實質的社會意義與合理性²³。如果直接將民法的「夫妻」解釋為包含同性伴侶，這將使同性伴侶的家族法制度與異性完全相同，這等於是繞過了國會的選擇與決定權²⁴。

同性事實婚已受到一定程度的法律保護（例如犯罪被害人給付）、部分效果可透過契約代替、高達 93% 人口所在的地方自治體已建立伴侶制度，且國會內部已有相關法律案提出並面臨審議要求。綜合上述因素，法院認為目前的差別待遇尚未達到違反憲法第 14 條第 1 項的程度。

（三）憲法第 13 條：合憲

法院在結論中警告，若國會繼續拖延，未能針對同性伴侶的法律保護進行充分審議與立法，「若現狀持續下去，在與憲法第 13 條、第 14 條第 1 項之關係上，將不可避免地產生違憲問題」。

三、小結

綜上所述，福岡高裁於 2024 年 12 月作出判決，而東京第二次高裁於 2025 年 11 月作出判決，在此之前已有 5 個高院判決之法院採取較為積極的態度，如福岡高裁已從憲法第 13 條推導出具體權利，東京高採取相對保守的立場。日本學

²¹東京高判令和 7 年 11 月 28 日（令和 6 年（ネ）第 1861 号）裁判所ウェブサイト，頁 45。

²² 判決書第 49-50 頁。

²³ 判決書第 51-55 頁。

²⁴ 判決書第 60-61 頁。

者渡邊泰彥批評，這份合憲判決的整個立論基礎，完全建立在「制憲當時的社會通念」這項單一且僵化的前提上²⁵，下段將就兩判決之解釋方法評析。

伍、解釋方法分析

一、福岡高裁解釋方法分析

（一）哲學方法

福岡高裁跳脫文意，採行探尋憲法背後意旨之哲學解釋方法，所謂哲學解釋方法係，依照德沃金的思想實驗，憲法條文係以一般性的「概念」(concepts)，而非特定的「觀念」(conceptions)的形式所寫下的，法官要詮釋具爭議性之憲法條文，必須進行自我批判的獨立思考²⁶。哲學解釋方法係對憲法忠誠的承諾，意味著我們必須透過解釋，使其成為「它所能達到的最佳狀態」²⁷。

福岡高裁跳過憲法第 24 條「兩性」、「夫婦」的明文，探求憲法最佳解釋之意旨，探求婚姻的本質概念，並認為婚姻自由直接從第 13 條推導出幸福追求權，透過解釋使其達到最佳的狀態，本為以為，其採取哲學解釋方法。

（二）抽象原旨主義

所謂抽象原旨主義，是指制憲者的意圖是將特定的「道德概念」的概念本身寫進憲法，而非他們當時對該概念的具體應用，申言之，此即與哲學方法相似，兩者都承認，法官必須對憲法文本，運用道德哲學去探究在當代最佳含義²⁸。是以，福岡高裁之主張，深入探求婚姻之本質，考量到婚姻對人而言是極為重要且根本的權利，本文以為，福岡高裁深入探究婚姻制度之核心，不侷限於制憲當時具體想像，應屬抽象原旨主義。

（三）結構主義、體系解釋

法官得藉由從憲法結構性原則中推論，以在困難案件中迴避或減少哲學方法之需求。憲法結構係指憲法所規定的各種關係，包含：聯邦政府與各州、聯邦政府與各部門，以及政府與人民間之關係，總體而言係指憲法所呈現職位、權利與

²⁵ 渡邊泰彥，同性の者同士の結合関係としての婚姻、家族、事実婚とは（結婚の自由をすべての人に訴訟東京第二次控訴審），新・判例解説 Watch ◆ 民法（家族法）No.6，vol.38，頁126（2026年）。

²⁶ SOTIRIOS A. BARBER & JAMES E. FLEMING, CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTIONS 27-29 (2007).

²⁷ *Id.* at 160.

²⁸ *Id.* at 82-83.

關係的整體安排²⁹。類似體系解釋，不單獨地觀察某法律，而係觀察此規範與他規範的關聯；這個法律規範和他個規範皆被特定於某法律領域中，形成體系³⁰。

在福岡高裁的判決中，法院不單獨看憲法第 24 條，而是結合第 13 條、第 14 條及第 24 條第 2 項綜合判斷，認為軌跡需一至，是以本文以為法院於此使用結構主義及體系解釋之方法。

日本學者河北洋介在此認為，憲法第 24 條第 1 項並非從「禁止」出發，而是從一開始就未明確禁止同性婚姻，須進一步從憲法第 14 條第 1 項、第 13 條（及第 24 條第 2 項等條文，判斷立法不作為是否違憲，作者稱此為「『容許』前提取向」以第 24 條第 1 項「容許但不要求」為前提，再透過其他條文審查違憲性³¹。

二、東京高裁解釋方法分析

（一）共識主義

共識主義者則參考目前社會對於文書詞彙意義的當前共識。Perry 教授認為，法院在 1973 年的 *Roe v. Wade* 走太遠，憲法權利應僅限於上述那些有共識的情形（指強暴、亂倫、胎兒畸形）；而在其他情形下，各州立法機關在憲法上應保有自由，得自行決定准許或禁止墮胎³²。

東京高裁在解釋第 14 條是否合憲時引用數據指出，目前日本嫡出子（婚生子女）的比例仍維持接近 100%（2021 年為 97.5%），這顯示一夫一妻制度目前依然具有實質的社會意義與合理性，當前社會對同性婚姻未達成共識，則應該回歸立法機關決定，而非交由司法機關解釋，本文以為此應為共識主義之解釋方法。

（二）具體意圖主義、文本主義、歷史解釋

具體意圖主義試圖將憲法意義與制憲者的具體偏見捆綁，一方面宣稱尊重制憲者，一方面假設制憲者寫下抽象美德時只是侷限在當時時代³³。歷史解釋係指，從法律資料中推斷立法者之意旨的方法，有時從法律被議決的歷史局勢，還有當時通行的法律見解及法釋譯學中，亦可推導出立法者制定該法之目的，但在歷史

²⁹ *Id.* at 120-121.

³⁰ INGEBORG PUPPE，蔡聖偉譯，法學思為小學堂法學方法論密集班，2 版，頁 142（2023 年）。

³¹ 河北洋介（註 15），頁 185。

³² SOTIRIOS & FLEMING, *supra* note 26, at 70-71.

³³ *Id.* at 84-85.

條件或法律觀點變遷下，該目的有多大程度有效³⁴？文本主義，透過查閱憲法文書的字面意義來找出憲法的涵義。而 **Rehnquist** 則認為活憲法不可接受，對 14 修正案解釋僅限縮在制憲者心中想像的內容³⁵。

東京高裁對於憲法第 24 條之解釋，將第 1 項「兩性」之解讀回到制憲當時僅限於「男女之」想像，忠於文本；並指出在制憲當時，「婚姻」預設為歷史與傳統上「異性之間」的結合關係，審議過程中完全沒有涉及同性結合的討論，將憲法第 24 條所定在制憲者在制憲當時的時空背景上，屬具體意圖主義及歷史解釋。且亦符合 **Rehnquist** 拒絕活憲法，其認為憲法的本質是在建立一個多數決的代議制民主，而非由非民選法官統治的制度。

（三）極簡主義

極簡主義的主張法官在裁定憲法問題時，應採取「狹義且在理論上不具雄心的步驟」。「一次只裁定一個案件」，避免宏大的道德宣告。將更多道德爭議留給民主程序解決³⁶。

針對同婚這一個重大人權議題，東京高裁未進行哲學式的道德解讀，而委由國會立法裁量，即係將道德爭議案件交由民主程序解決。另以日本學者山元一於文章中表示，平等權不僅涉及財產和利益分配之平等性，還應理解為具有禁止國家府與某些群體「劣性的污名」。若不允許同性伴侶和異性伴侶使用相同制度，及可能是對社會傳達對於同性伴侶的污名化³⁷。當法院將少數群體的權利交給多數決時，可能更合理化歧視，如同美國隔離但平等。

三、小結

同婚訴訟的勝敗，表面上是法條適用的結果，實質上是法官選擇了何種「憲法解釋方法」的結果。在同時有著「憲法所云就是法官所云」及「法官個人價值與憲法無關」兩個極端論調的美國，經歷司法謙抑與司法積極主義的拉鋸之後，雖然承認法院可藉由解釋衍生出非列舉權，但也一致認為須採取警慎態度³⁸。

另外，**John Ely** 代議補強理論，**Ely** 稱其所倡議的是一種「參與導向、代議補強」是的違憲審查。違憲審查的目的在確保政治過程的公開與開放，不應涉及

³⁴ INGEBOG PUPPE，蔡聖偉譯（註 30），頁 132-136。

³⁵ SOTIRIOS & FLEMING, *supra* note 26, at 21-25.

³⁶ *Id.* at 140.

³⁷ 山元一（註 7），頁 58-59。

³⁸ 廖元豪，憲法研究方法論—時代變遷如何作為「非列舉權利」之基礎？，收於：法學研究方法論憲法編，頁 191（2023 年）。

實體價值的選擇。僅於代議制度失靈時，及代議決策之程序不知得信任時，法院始應介入補強，代議失靈包含：當權者阻塞政治變遷管道、多數因單純敵意，或懷有成見，而使少數處於不利地位³⁹。

本文以為，同性婚姻正是代議民主失靈下的產物，因多數的成見與刻板印象，而長期在政治過程中處於劣勢，東京高裁將同婚議題交由國會以民主程序決定，儼然更加深其劣勢。而在判斷何者為應受保護之弱勢時，法院如同 SOTIRIOS & FLEMING 兩位作者在書中一再強調的，無論用何解釋方法都難以規避哲學解釋，須深入探求憲法本質，作出最佳解釋。但法院在司法謙抑與司法積極主義之間亦應採取審慎之態度，如同我國釋字第 748 號解釋，探求婚姻之本質，宣告系爭立法不作為違憲，同時也保留裁量權給立法者，即為適例。

陸、結論

本文首先介紹日本違憲審查制度，及日本同婚案至今的發展，繼而爬梳日本同婚系列訴訟中的主要爭點。接著，針對現有判決找出結論完全相反之「福岡高裁」及「東京第二次高裁」判決，分析其所使用之解釋方法。期望在不久將來日本最高裁的判決能如同我國釋字第 748 號解釋一般，使同性戀者也有和異性戀相同的結婚自由。

³⁹ 湯德宗，違憲審查與動態平衡權力分立新論卷二，頁 14-15（2014 年）。

參考文獻

中文文獻

專書

湯德宗（2014），*違憲審查與動態平衡權力分立新論卷二*，增訂 4 版，臺北：天宏。

湯德宗（2025），*釋憲學思心路下冊*，臺北：時英。

廖元豪（2023），*憲法研究方法論—時代變遷如何作為「非列舉權利」之基礎？*，收於：*法學研究方法論憲法編*，初版，頁 173-202，臺北：元照。

Ingeborg Puppe 著，蔡聖偉譯（2023），*法學思為小學堂法學方法論密集班*，2 版，臺北：元照。

期刊論文

張震（2016），*我國與日本違憲審查制度之比較*，*社科法政論叢*，4 期，頁 89-118。

外文文獻

Barber, Sotirios A., and James E. Fleming. 2007. *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*. New York, NY: Oxford University Press.

山元一（2024），*日本的同性婚與憲法*（張惠東譯，日文原名：「日本における同性婚と憲法」），*公法研究*，9 期，頁 1-82。

河北洋介（2026），*同性婚訴訟に関する一考察*，*慶應法學*，NO.56，頁 179-203。

渡邊泰彦（2026），*同性の者同士の結合関係としての婚姻、家族、事実婚とは（結婚の自由をすべての人に訴訟東京第二次控訴審）*，*新・判例解説 Watch ◆ 民法（家族法）No.6*，vol.38，頁 123-126。

網路資料

張郁婕，*日本同婚訴訟的一大挫敗：系列訴訟二審首度出現合憲判決，2026 年決戰最高法院*，2025 年 12 月 1 日，https://global.udn.com/global_vision/story/8664/9174443（最後瀏覽日：2026 年 6 月 9 日）。